

1500324-85.2022.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria da Conceição Pinto Vendeiro

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

CLAUDEMIR BALBINO DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

CLAUDEMIR BALBINO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06 do Código Penal, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

3ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, . - Vila Conceição

CEP: 09912-010 - Diadema - SP

Telefone: (11) 4056-6600 - E-mail: diadema3cr@tjsp.jus.br

1500324-85.2022.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500324-85.2022.8.26.0537 Controle nº 230/2022

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado e Réu:

CLAUDEMIR BALBINO DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria da Conceição Pinto Vendeiro

VISTOS, ETC.

CLAUDEMIR BALBINO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no

art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06 do Código Penal, porque no dia 13 de fevereiro de 2022, por volta das 10:00 horas, na Rua Salgueiro, altura do n.º 130, Bairro Jardim Campanário, adquiriu e trazia consigo, para fins de entrega e consumo de terceiros, maconha, cocaína e "crack", drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva por decisão da Juíza de Plantão (fls. 63/65). Foi apresentada defesa prévia (fls. 95/96), sendo a denúncia recebida em 25.04.22 (fls. 100/101). Na instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. O réu foi interrogado no final, em razão do princípio da ampla defesa e conforme entendimento do STF de que o art. 400 do CPP se aplica aos ritos especiais.

A Dr.^a Promotora de Justiça requereu a procedência da ação por entender estarem provados os fatos descritos na denúncia, com aumento da pena pela variedade das drogas e dupla reincidência, fixação de regime fechado e perda do dinheiro apreendido.

O Defensor requereu a absolvição por insuficiência de provas ou em caso de eventual a aplicação do art. 387, §2.º, do CPP, que seja afastada a agravante da reincidência e fixação de regime semiaberto.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

Na fase policial (fls. 14), o réu negou a prática do crime. Disse que não sabia como sua carteira e documentos foram parar dentro da sacola plástica. Narrou que sua carteira sumiu há cerca de uma semana e desconfiava que Wanessa a tinha pegado, uma vez que moravam na mesma casa. Disse que estava no local dos fatos para comprar "crack" e que trazia no bolso algumas pedras de "crack" e R\$ 15,00. Falou que a sacola com drogas pertencia ao traficante de quem havia comprado "crack", homem conhecido como "Alemãozinho" e que se evadiu com a chegada dos guardas civis, dispensando a sacola no chão. Informou que possuía uma condenação por tráfico de drogas e não tinha filhos.

Em juízo, negou a prática do crime, alegando que comprou drogas e como não tinha dinheiro deixou sua carteira "empenhada". No dia dos fatos foi até o local para pagar a dívida (R\$15,00) e estava esperando o traficante chegar, quando foi abordado por policiais. Informou que a sacola com drogas estava junto da menor e que havia mais dois homens no local. Não estava com a sacola com drogas. Tem condenações por tráfico e furto.

Os guardas civis, tanto na fase extrajudicial (fls. 07/09), quanto em juízo, disseram que estavam em patrulhamento quando avistaram quatro pessoas, três homens e uma mulher, em um local conhecido como ponto de venda de drogas. Relataram que ao vê-los o réu dispensou uma sacola plástica ao solo. Então, resolveram abordar os homens e a mulher. Narraram que em revista pessoal, nada de ilícito foi localizado na posse deles, porém, em vistoria na sacola plástica dispensada pelo réu localizaram uma carteira contendo documentos pessoais deste, papéis com anotações típicas de contabilidade do tráfico e cerca quantidade de diferentes tipos de drogas, embaladas em porções individualizadas, e a quantia de R\$ 108,00. Afirmaram que tanto o réu, quanto os outros dois homens e a mulher, que depois apuraram tratar-se de menor de idade, negaram ser os proprietários das drogas.

O fato de a testemunha ser agente de segurança não a torna impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/64 e 168/199), estando seus depoimentos em consonância com o conjunto probatório.

"PROVA- Declaração da vítima e depoimento de Policiais - Eficácia:

As declarações prestadas pela vítima e os depoimentos de Policiais, se não confrontados por nenhum elemento que indique sua invalidez são provas absolutamente legítimas para sustentar um decreto condenatório, uma vez que o ofendido, por desconhecer o acusado, não tem razão para levianamente incriminá-lo, se inocente; e os Milicianos apenas pela função que exercem não podem ter suas afirmações comprometidas, já que não possuem interesse na condenação" (Apelação n.º

1.301.549/7- 11.^a Câmara - j. 24.06.02, cf. Ementário do TACrimSP n.º 35, p. 24).

A quantidade de drogas apreendidas (fls. 17 - 10 papelotes de cocaína, 26 pedras de "crack" e 22 porções de maconha) e diversidade (cocaína, "crack" e maconha),

aliados à falta de comprovação de ocupação lícita, o que é incompatível com a condição de usuário e, ainda, considerando que estava dividida em invólucros, que foi apreendido dinheiro, não sendo provada a sua procedência, além de anotações manuscritas, que a carteira e documentos do réu estavam junto com os entorpecentes, bem como os depoimentos dos policiais demonstram o tráfico, pois não teria como adquirir essa quantidade se não fosse traficante.

Segundo a jurisprudência:

"Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização" (RJTJSP 75/343). Nesse sentido: RT 538/380.

"Tráfico de maconha- Quantidade da erva apreendida, aliada a outras circunstâncias, que induz à certeza da destinação ao comércio" (RJTJSP 97/492). No mesmo sentido: RJTJSP 123/473.

As negativas do réu estão isoladas nos autos, porque apresentou versões diversas, ou seja, na delegacia, narrou que seus documentos sumiram e não sabia como foram parar na sacola com drogas; já em juízo que "empenhou" a carteira, pois comprou drogas e no dia dos fatos estava esperando o traficante para pagar o valor que devia (R\$15,00) e pegá-la de volta, mas observo que o réu sequer estava com dinheiro em seu poder quando abordado pelos policiais, sendo achada quantia superior apenas na sacola contendo drogas, que o mesmo dispensou, conforme depoimentos uníssomos dos policiais nas duas fases, pelo que estava no local para o tráfico. Há que se consignar que traficantes não ficam com documentos como garantia de pagamento, mesmo porque há turnos e se mesmo que fosse entregue para um dos traficantes, ficaria em poder deste e não na sacola com drogas.

Irrelevante que não tenham sido presenciados atos de mercancia, posto que denunciado pelas condutas de adquirir e trazer consigo.

Portanto, não é caso de absolvição como requerido pela defesa.

Não é caso de desclassificação para o crime do art. 28, porque a quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder do réu (10 papérolas de cocaína, 26 pedras de "crack" e 22 porções de maconha) demonstram que se destinava ao tráfico.

Assim, impõe-se a condenação do acusado, posto que a materialidade está provada pelo laudo de constatação (fls. 20/22) e laudo definitivo (fls. 86/88).

Passo a individualizar a pena a ser aplicada ao acusado, que segundo consta dos autos possui antecedentes (fls. 44 - proc. 41546-66.1998 - pena extinta pela prescrição executória em 16.03.09) e é reincidente (fls. 43/44 - proc. 19289-51.2015 - pena julgada extinta pelo cumprimento em 27.02.21).

O art. 5.º inc. XLVI da Constituição Federal prevê que "a lei regulará a individualização da pena" e o art. 61, inc. I, do Código Penal determina que a reincidência é circunstância agravante da pena.

Conforme R.E. 723.211, Rel Min. Ricardo Lewandowski, j. 25.06.13:

"O Plenário desta Corte, no julgamento do RE453.000/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, no dia 4/4/2013, em regime de repercussão geral, julgou o mérito do tema 114 e negou provimento ao RE que alegava a inconstitucionalidade do agravamento da pena em virtude da reincidência, consolidando o entendimento de que não configura bis in idem.

"Desse modo declarou ser constitucional a aplicação do instituto da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal)".

Assim, a reincidência será considerada como circunstância agravante.

Levando em conta as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, especialmente que possui antecedentes criminais, fixo a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, à razão mínima por inexistirem elementos quanto à real situação econômica do acusado. Não é caso de aumento da pena-base diante da variedade de drogas, uma vez que no caso em tela a quantidade apreendida é pequena (nesta Comarca inferior a 100).

Aumento a pena de 1/6 pela reincidência.

O réu não faz jus à redução do art. 33, § 4.º, porque é reincidente e, portanto, não preenche um dos requisitos legais (não é primário).

Não se trata de tráfico privilegiado, pelo que não incide no caso em tela o decidido no HC 596.603 do STJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 08.09.2020.

O regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, pois conforme prevê o art. 33, § 2.º, "b" e "c" só se aplicam regimes mais brandos ao "condenado não reincidente". As circunstâncias não são favoráveis, pois é reincidente específico (fls. 43/44 – proc. 19289-51.2015 – pena julgada extinta pelo cumprimento em 27.02.21), demonstrando que não foi um fato isolado em sua vida. Trata-se de crime de extrema gravidade, uma vez que causa dependência física e psíquica atingindo inúmeros usuários, provocando perda de emprego, envolvimento em delitos para comprarem drogas, venda de bens inclusive de familiares para satisfação do vício, acarretando efeitos deletérios para a sociedade.

Inviável a conversão em restritiva de direitos ou "sursis" diante do montante da pena e por ser reincidente.

Inaplicável o disposto no art. 387, §2.º, do CPP, diante de sua inconstitucionalidade por violar os princípios da individualização da pena, do juiz natural e da igualdade, já que a fixação da pena e regime estão previstos nos arts. 33 e 68, ambos do Código Penal (norma de direito material), sendo que a progressão de regime deve ser apreciada pelo juiz da execução de acordo com o art. 112 da LEP que é lei especial e prevalece sobre a geral, ou seja, "Lex specialis derogat generali" (Lei especial derroga a geral), não se justificando que o preso provisório possa obter tal benefício sem preencher os requisitos da LEP. Ademais, havendo recurso será expedida guia de recolhimento provisória, pelo que não haverá qualquer prejuízo, pois a progressão será apreciada pelo juízo competente. Além disso, sequer preenche o lapso temporal para tanto (preso em 13.02.22 pelo que ainda que considerado 2/5 só ocorreria em 01.11.24).

Por outro lado, "ad argumentandum", ainda que se considere a detração conforme entendimento do STJ, o fato é que o regime não está atrelado apenas à pena, mas também às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, pelo que diante da reincidência (circunstância judicial agravante) e ser praticado durante pandemia não é recomendável outro regime diverso do acima fixado.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação e, em consequência, CONDENO CLAUDEMIR BALBINO DA SILVA à pena de 6 (SEIS) ANOS, 9 (NOVE) MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, INICIALMENTE NO REGIME FECHADO, e 680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA, à razão mínima, por se achar incurso no art. 33, "caput", da Lei n.º 11.343/06.

Tendo em vista que o réu foi preso em flagrante por crime equiparado aos hediondos previsto na Lei 8072/90, bem como por estarem presentes os requisitos da preventiva, sendo crime de extrema gravidade, fazendo-se necessária a prisão para garantia da ordem pública para evitar a prática de novos crimes de gravidade e para assegurar a aplicação da lei penal, posto que nada há que o vincule ao distrito da culpa (não comprovou residência fixa nem ocupação lícita), inclusive conforme decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, recomende-se na prisão em que se encontra.

Sem custas (Lei n.º 11.608/03 por ser beneficiário da Assistência Judiciária (art. 5.º, inc. LXXIV, da Constituição Federal; STF- RE 313348 AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 15.04.03).

Considerando que o dinheiro apreendido (fls. 17 e 41/42) conforme prova produzida é proveito do tráfico, determino o perdimento em favor da União (art. 63 da Lei n.º 11343/06), providenciando-se o necessário após o trânsito em julgado (art. 63 da Lei n.º 11343/06).

Quanto às folhas de caderno apreendidas (fls. 17), tendo em vista que não houve insistência na juntada do laudo pericial (exame pericial requisitado às fls. 23, cujo ainda não está disponível – fls. 127), como não possuem valor econômico, oficie-se desde já informando que não interessam mais aos autos, podendo ser eliminadas.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do acusado no Rol dos Culpados, oficie-se para incineração da droga mantida para contraprova (fls. 66), providencie-se o necessário para transferência do dinheiro ao FUNAD, comunicando-se à SENAD (art. 63, §4.º, da Lei n.º 11343/06) e o cálculo da multa, abrindo-se vista às partes.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Façam-se as anotações e

comunicações de praxe.
Diadema, 04 de maio de 2022.

MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO VENDEIRO
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA